

당사자표시는 '원고(선정당사자)'의 형식으로 선정당사자라는 표기를 괄호 안에 병기하고, 판결서의 말미에는 별지로 선정자들의 성명과 주소를 기재한 '선정자 명단'을 작성하여 첨부한다. 이때 '선정자 명단'에는 선정당사자도 선정자로서 포함하는 것이 실무이고, 이러한 표기는 위법하다고 볼 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 참조).

한편 선정당사자가 이행판결을 받으면 그 판결에 기하여 선정자를 위하여 또는 선정자에 대하여 강제집행을 할 수 있으므로, 이행판결의 주문에서는 각 선정자가 수령하거나 또는 부담하여야 할 급부의 내용을 개별적으로 명시하는 것이 실무이다. 이 경우 판결의 주문이나 이유에서 선정자들을 표시할 때에는 '선정자 ○○○'라고 표시하는 것이 실무이다. 그러나 선정당사자의 청구나 선정당사자에 대한 청구를 기각하거나 각하하는 경우에는 주문에 '원고(선정당사자)' 또는 '피고(선정당사자)'라고만 기재하는 것이 실무이다.

4. 판결의 효력

제3자가 소송담당자로서 소송수행한 결과로 받은 판결은 권리관계의 주체인 본인에게 미친다(민소 218조 3항). 제3자의 소송담당 가운데 파산관재인, 회생채무자의 관리인과 같은 '갈음형' 소송담당자, 직무상의 당사자, 그리고 선정당사자 등 임의적 소송담당자의 경우에는 민사소송법 218조 3항이 적용되어 제3자가 받은 판결의 기판력이 권리주체인 사람에게 미치는 것에는 아무런 의문이 없다.

그러나 채권자대위소송을 제기한 채권자, 회사대표소송을 수행하는 주주, 채권에 대한 질권을 행사하는 질권자 등과 같이 제3자가 권리주체인 사람과 병행하여 소송수행권을 갖는 '병존형'의 경우에도 제3자가 받은 판결의 효력이 권리주체인 사람에게 미치는지는 논의의 여지가 있다. 만약 전면적으로 기판력이 미친다면, 제3자인 소송담당자가 불성실하게 소송수행을 하여 패소 판결을 받은 경우에도 기판력을 받게 되어 다시 소제기를 못하게 됨으로써,

결국 권리주체인 사람의 소송수행권이 침해·상실되는 결과가 된다. 판례는 그중에서 채권자가 채권자대위소송을 제기하여 받은 판결은 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 알았을 때 채무자에게도 그 효력이 미치는 것으로 보고 있다(대법원 1975. 5. 13. 선고 74다1664 전원합의체 판결). 이때 채무자에게도 기판력이 미친다는 의미는 채권자대위소송의 소송물인 피대위채권의 존부에 관하여 채무자에게도 기판력이 인정된다는 것이고, 채권자대위소송의 소송요건인 피보전채권의 존부에 관하여 당해 소송의 당사자가 아닌 채무자에게 기판력이 인정된다는 것은 아니다. 따라서 채권자가 채권자대위권을 행사하는 방법으로 제3채무자를 상대로 소송을 제기하였다가 채무자를 대위할 피보전채권이 인정되지 않는다는 이유로 소각하 판결을 받아 확정된 경우 그 판결의 기판력이 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권의 이행을 구하는 소송에 미치는 것은 아니다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2011다108095 판결).

제6절 당사자의 변경(소의 주관적 변경)과 피고의 경정

1. 총 설

소송절차의 계속 중에 제3자가 새로 소송에 가입하는 기회에 종전 당사자가 그 소송에서 탈퇴하는 경우를 널리 ‘당사자의 변경’이라 한다. 당사자의 변경, 즉 ‘소의 주관적 변경’은 다시 신당사자가 탈퇴자의 소송상 지위를 승계하는 ‘소송승계’[자세한 내용은 제11장(소송참가와 소송승계) 제5절 참조]와 신당사자가 탈퇴자의 소송상 지위를 승계하지 않는 ‘임의적 당사자변경’으로 나누어 볼 수 있다. 또 ‘임의적 당사자변경’은 종전의 당사자를 갈음하여 제3자를 가입시키는 ‘당사자의 교체’와 종전의 당사자를 그대로 둔 채 누락된 당사자 또는 새로운 당사자를 가입시키는 ‘당사자의 추가’의 두 가지 형태가 있다.

2. 임의적 당사자변경의 허용 여부

당사자의 동일성을 해하지 않는 범위 내에서만 인정되는 ‘당사자표시정정’과는 달리 ‘임의적 당사자변경’은 당사자의 동일성을 해치기 때문에 원칙적으로 허용되지 아니한다.

다만 민사소송법은 소송경제와 당사자의 편의 도모라는 차원에서 3가지 형태의 임의적 당사자변경을 허용하고 있다. ① ‘당사자의 추가’에 해당하는 필수적 공동소송인의 추가(민소 68조), ② 예비적·선택적 공동소송인의 추가(70조), ③ ‘당사자의 교체’에 해당하는 피고의 경정(260조)이 그것이다. 3가지 형태 모두 제1심 변론 종결 시까지에 한하여 가능하며, 그 밖의 임의적 당사자변경은 허용되지 않는다. 그중 앞의 두 가지는 제10장(공동소송) 제3절, 제4절 참조.

3. 피고의 경정

가. 총 설

경정은 피고나 피신청인의 경정만이 가능하며, 소제기자인 원고나 신청인의 경정은 허용되지 아니한다. 따라서 법인이 아닌 사단인 부락의 구성원 중 일부가 제기한 소송에서 당사자인 원고의 표시를 부락으로 정정하거나, 회사의 대표이사가 개인 명의로 소를 제기한 후 회사를 당사자로 추가하고 그 개인 명의의 소를 취하함으로써 당사자의 변경을 가져오는 당사자추가신청은 허용되지 않는다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92다50232 판결, 대법원 1998. 1. 23. 선고 96다41496 판결).

나. 피고경정의 요건

피고의 경정은 ① 원고의 신청에 의하여만 가능하고, ② 원고가 피고를 잘못 지정한 것이 분명한 경우라야 하며, ③ 교체 전후를 통하여 소송물이 동일하여야 하고, ④ 피고가 본안에 관하여 응소한 때, 즉 본안에 관하여 준비

서면을 제출하거나 변론준비기일에서 진술하거나 변론을 한 뒤에는 피고의 동의를 요하며(민소 260조 1항 단서), 피고가 경정신청서를 송달받은 날부터 2주일 내에 이의하지 않으면 동의한 것으로 본다(4항). ⑤ 또한 피고의 경정은 제1심법원이 변론을 종결할 때까지만 가능하다.

이처럼 민사소송법에서는 피고경정이 가능한 범위나 신청권자, 시기 등에서 매우 제한적으로 허용된다. 한편 가사소송법에서는 피고의 경정이 가능한 시기를 사실심의 변론 종결 시까지로 완화하고 있다(가소 15조 1항).

여기서 ‘피고를 잘못 지정한 것이 분명한 경우’란 청구취지나 청구원인의 기재 내용 자체로 보아 원고가 법률적 평가를 그르치는 등의 이유로 피고의 지정이 잘못된 것이 분명하거나 법인격의 유무에 관하여 착오를 일으킨 것이 분명한 경우 등을 말하고, 누가 피고가 되어야 하는지를 증거조사를 거쳐 사실을 인정하고 그 인정 사실에 기초하여 법률 판단을 해야 인정할 수 있는 경우는 이에 해당하지 않는다(대법원 1997. 10. 17. 자 97마1632 결정). 따라서 원고가 공사도급계약상의 수급인으로 기재된 사람을 실제 수급인이라고 주장하면서 그를 피고로 하여 소를 제기하였다가 심리 도중 변론에서 피고 측 답변이나 증거에 따라 이를 번복하여 피고보조참가인이 실제 수급인이라고 하면서 피고경정을 구하는 경우 수급인이 누구인지는 증거조사를 거쳐 사실을 인정하고 그 인정 사실에 기초하여 법률 판단을 하여야 인정할 수 있는 사항이므로, 피고를 잘못 지정한 것이 분명한 경우에 해당한다고 볼 수 없어 피고경정이 허용되지 아니하며, 이러한 경우에는 예비적·선택적 공동소송인으로 추가할 수는 있을 것이다.

실무상 피고경정이 허용되는 예로는, 주식회사를 피고로 하여야 할 것이 명백함에도 그 대표이사 개인을 피고로 한 경우, 지역농업협동조합을 상대로 해야 할 것이 명백함에도 농업협동조합중앙회를 상대로 한 경우를 들 수 있다.

다. 피고경정신청의 방식

피고의 경정은 신소의 제기와 구소의 취하의 실질을 가지므로, 신청권자인 원고가 서면으로 신청하여야 한다(민소 260조 2항). 신청서에는 새로 피고가 될 사람의 이름, 주소와 경정신청의 이유를 적어야 한다(민소규 66조). 새로 피고가 될 사람의 이름, 주소를 적도록 한 것은 경정신청을 허가하는 결정을 한 때에는 새로운 피고에게 그 허가결정의 정본과 소장을 송달하여야 하기 때문이다(민소 261조 2항). 청구취지와 청구원인은 그것이 소장에 이미 기재되어 있는 한 새로운 피고에게 소장부분을 다시 송달하므로, 이를 피고 경정신청서에 적을 필요가 없다. 그 밖에도 신청서에는 사건의 표시, 신청인과 대리인의 이름, 주소와 연락처, 덧붙인 서류의 표시, 작성한 날짜, 법원의 표시 등을 적고 신청인 또는 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 한다(민소규 2조). 신청서에는 인지를 붙이지 않고 문건으로 전산입력하며 기록에 가철한다(인지액·편철방법예규).

한편 민사소송법의 규정에도 불구하고 소액사건에서는 구술로도 피고경정신청을 할 수 있다고 해석되는데(소액 4조 참조), 그 경우에는 위 기재사항을 말로 진술하면 될 것이다.

라. 피고경정신청에 대한 허부의 재판과 불복

피고경정신청서는 종전의 피고에게 소장부분을 송달하지 아니한 경우를 제외하고는 종전 피고에게 이를 송달하여야 한다(민소 260조 3항). 원고의 피고경정신청에 대하여 법원은 결정으로 허부의 재판을 하여야 하며, 그 허부의 결정은 종전의 피고에게 소장부분을 송달하지 아니한 경우를 제외하고는 종전 피고에게 송달할 것을 요한다(261조 1항). 한편 새로운 피고에 대해서는 경정신청을 허가하는 결정을 한 때에 한하여 결정의 정본과 함께 소장부분을 송달하여야 한다(2항).

결정을 허가하는 결정에 대하여는 동의권을 가진 종전 피고가 경정에 부

동의하였음을 사유로 하는 경우에 한하여 즉시항고할 수 있을 뿐이고(민소 261조 3항) 그 밖의 사유로는 불복할 수 없으며, 더욱이 피고경정신청을 한 원고가 그 허가결정의 부당함을 내세워 불복하는 것은 허용될 수 없다(대법원 1992. 10. 9. 선고 92다25533 판결).

피고경정신청을 기각하는 결정에 대하여 불복이 있는 원고는 민사소송법 439조의 규정에 의한 통상항고를 제기할 수 있으므로 그 결정에 대하여 특별항고를 제기할 수는 없다(대법원 1997. 3. 3. 자 97오1 결정).

마. 피고경정 허가결정의 효력

경정허가결정이 있는 때에는 종전의 피고에 대한 소는 취하된 것으로 본다(민소 261조 4항). 따라서 종전 피고에 대하여는 소송계속의 효과가 소멸되었기 때문에 더 이상 그에 관한 심리를 하여서는 안 된다.

피고의 경정은 구소의 취하 및 신소의 제기이므로 종전 피고의 소송진행의 결과는 새로운 피고가 원용하지 않는 한 새로운 피고에게 효력이 없고, 법원은 새로운 피고에 대하여 새로 변론절차를 열어야 하는 것이 원칙이다. 따라서 재판장은 피고경정을 허가한 뒤 첫째 변론기일에 종전 피고의 소송진행 결과를 원용할 것인지 여부를 확인하여 그 취지가 조서에 기재되도록 하여야 할 것이다.

또한 피고의 경정도 새로운 피고에 대하여는 소의 제기에 해당하므로, 그로 인한 시효중단과 기간준수의 효과는 경정신청서의 제출 시에 발생한다(민소 265조).

제9장

당사자

-
- 제1절 총 설 358
 - 제2절 당사자의 확정 358
 - 제3절 당사자능력 365
 - 제4절 소의 종류와 당사자적격 370
 - 제5절 제3자의 소송담당 375
 - 제6절 당사자의 변경(소의 주관적 변경)과
피고의 경정 382

제1절 총 설

민사소송에서 당사자란 자기의 이름으로 국가의 권리보호를 요구하는 측과 그 상대방을 말한다. 민사소송의 당사자가 되기 위해서는 소송의 주체가 될 수 있는 일반적 능력인 당사자능력이 있어야 하고 유효한 소송행위를 하기 위하여 소송능력이 있어야 한다. 아울러 특정 소송사건에서 당사자로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 당사자적격을 갖추어야 한다.

당사자능력, 당사자적격은 본안판결을 받기 위한 전제로서 필요한 소송요건의 하나이므로 이것이 결여되면 판결로 소를 각하하여야 한다.

소송능력은 개개 소송행위의 유효요건이므로 소송무능력자의 소송행위나 이에 대한 상대방의 소송행위는 무효이다. 미성년자 또는 피성년후견인은 원칙적으로 법정대리인에 의해서만 소송행위를 할 수 있고, 피한정후견인은 한정후견인의 동의가 필요한 행위에 관하여는 대리권 있는 한정후견인에 의해서만 소송행위를 할 수 있다(민소 55조).

제2절 당사자의 확정

1. 당사자의 특징을 위한 표시

현실적으로 계속되어 있는 소송사건에서는 원고가 누구이며 피고가 누구인가를 명확히 하여야 하는데, 이를 ‘당사자의 확정’이라고 한다. 소장에는 원고와 피고가 누구인가를 다른 사람과 구별할 수 있을 정도로 표시하여야 한다. 어떤 당사자 사이에 판결절차가 개시되었는가를 명확히 하여 그 소에 의하여 요구된 판결의 기판력이 미치는 주관적 범위(민소 218조)를 명확히 하기 위해서이다.

당사자를 표시하는 방법으로는 원고·피고 등 당사자의 지위를 기재한 다음, 자연인의 경우에는 성명과 주소를, 법인 또는 법인이 아닌 사단·재단(민소 52조)의 경우에는 명칭(회사의 경우에는 상호)과 주된 사무소(회사의 경우에는 본점)의 소재지를 기재하는 것이 보통이다.

당사자가 자연인인 경우 판결서(화해·조정·포기·인낙조서와 화해권고결정, 조정을 갈음하는 결정을 포함한다)에는 당사자 등의 성명과 주소를 기재하여야 하는데, 한글이름이 같은 여러 사람을 표시하여야 하는 경우에는 해당 당사자 등의 성명으로부터 한 칸 띄어 괄호하고 그 안에 생년월일이나 한자성명 중 어느 하나를 기재하거나 '모두 병기하여야 하므로(재판서예규 9조 1항), 소장에도 원고 자신의 생년월일은 물론이고 확인이 가능한 범위 내에서 피고의 생년월일이나 한자명도 반드시 기재하여야 한다. 당사자는 통상 이름과 주소에 의하여 특정되지만 보다 정확을 기하기 위하여 생년월일이나 한자성명을 기재하도록 하고 있는 것이다.

주소의 기재는 당사자의 특정뿐만 아니라 소장이나 준비서면 등 서류를 송달하기 위해서도 필요하다. 재판서의 주소와 건물 표기 방식에 관하여는 '도로명주소 도입에 따른 재판서의 주소와 건물 표기에 관한 업무처리지침'에서 정하고 있다.

주소가 외국에 있는 경우에는 외국어에 의한 주소를 한글로 표시한 다음 해당 외국문자를 괄호 안에 병기하여야 한다. 소장에 주소를 기재할 때에는 송달을 염두에 두어야 하므로, 특히 아파트나 다세대주택 등인 경우에는 동호수를 명확히 기재하여야 하고, 빌딩의 이름이나 개인 상호까지 기재하는 것이 좋다. 또한 당사자나 그 대리인에 대한 간편한 연락방법으로 전화번호·팩시밀리번호 또는 전자우편주소 등을 적어야 한다(민소규 2조 1항 2호). 소송절차의 각 단계에서 당사자 또는 대리인에 대한 통지 등이 우편송달의 방법에 국한되지 아니하고 전화·팩시밀리·전자우편 등 다양한 수단이 활용되기 때문이다(민소 167조 2항, 민소규 45조, 46조 등).

법인이 당사자인 경우에는 법인등기기록에 적힌 정확한 명칭과 주된 사무소 소재지를 기재하고, 외국법인인 경우에는 외국어에 의한 명칭 전체(회사 등을 의미하는 부분까지)를 한글로 표시한 다음 해당 외국문자를 괄호 안에 병기한다. 법인의 상호가 변경되었는데 부동산등기기록에는 종전 상호로 표시된 채 존속하는 때에는 그것이 동일한 법인임을 명확히 하기 위하여 종전 상호를 병기하는 것이 좋다. 법인등기기록상의 본점 또는 사무소가 실제와 다를 때에는 실제 본점 또는 사무소 소재지를 병기한다.

2. 당사자 확정의 기준

소장의 당사자란의 기재뿐만 아니라 청구의 취지·원인 그 밖의 일체의 기재사항 등 소장의 전체를 기준으로 합리적으로 해석 판단하여야 한다(이른바 실질적 표시설, 대법원 1996. 3. 22. 선고 94다61243 판결). 실무상 당사자 확인이 문제 되는 사례들을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 성명모용(姓名冒用)소송

갑이 권한 없이 을 명의로 소를 제기하고 소송을 수행하거나(원고 측의 모용) 을에 대한 소송에서 갑이 권한 없이 을 명의를 참칭하여 소송을 수행하는(피고 측의 모용) 성명모용소송의 경우, 피모용자인 을이 당사자이고 모용자인 갑은 당사자가 아니며 모용자의 소송행위는 무효이다. 따라서 원고 측 모용의 경우 피모용자가 모용자의 소송행위를 승인하지 아니하는 한 그 소는 부적법하므로 각하되어야 하고 그 소송비용은 모용자가 부담하게 되며, 피고 측 모용의 경우에는 모용자를 소송절차에서 배제하고 피모용자를 소송절차에 관여시켜야 한다.

법원이 모용사실을 간과하고 피모용자를 당사자로 한 판결을 한 경우 그 판결의 효력은 피모용자에게 미치고 피모용자는 판결확정 전에는 상소에 의하여, 판결확정 후에는 재심으로 다룰 수밖에 없다(대법원 1964. 3. 31. 선고 63다656 판결). 다만 원고가 피고의 주소를 허위로 표시하여 피고에 대한 소

송서류를 그 허위주소로 보내고 피고가 아닌 다른 사람이 그 소송서류를 받아 자백간주 원고 승소 판결이 선고되고 그 판결정본이 위와 같은 방법으로 피고에게 송달된 경우 그 판결정본의 송달은 부적법하여 무효이고 피고는 아직도 판결정본의 송달을 받지 않은 상태에 있으므로, 피모용자인 피고는 재심이 아닌 항소제기를 해야 한다는 것이 판례이다(대법원 1978. 5. 9. 선고 75다634 전원합의체 판결).

(2) 사망자를 당사자로 한 소송

원고가 피고의 사망사실을 모르고 선의로 사망자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우(대법원 1983. 12. 27. 선고 82다146 판결), 피고의 사망사실을 알고 있더라도 그 상속인이 누구인지 알 수 없어 사망자를 피고로 표시하여 소를 제기한 후 사실조회 등을 통하여 상속인을 확인한 경우(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다99040 판결) 원고는 상속인을 피고로 하는 당사자표시정정을 할 수 있다. 표시설에 의하면 당초 사망자를 상대로 한 소송은 당사자가 실재하지 아니한 소송으로 되어 부적법하고, 이를 상속인으로 정정하는 것은 동일성을 벗어나 허용될 수 없으나, 위와 같은 경우에는 소장의 전체를 기준으로 합리적으로 해석하여 이에 대한 예외를 인정하고 있는 것이다. 이때 실질적인 피고로 해석되는 상속인은 실제로 상속을 하는 사람을 가리키므로, 상속을 포기한 사람은 이에 해당하지 아니하고 후순위 상속인이더라도 선순위 상속인의 상속포기 등으로 실제로 상속인이 되는 경우에는 이에 해당한다(대법원 2006. 7. 4. 자 2005마425 결정, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다49964 판결). 또한 사망한 자를 당사자로 하여 소를 제기한 후 그 사망사실을 발견하고 수계신청을 한 경우에는 그것은 당사자표시정정신청의 취지로 볼 수 있다(대법원 1962. 8. 30. 선고 62다275 판결). 그러나 사망자를 피고로 하여 제소한 제1심에서 원고가 상속인으로 당사자표시정정을 함에 있어서 일부상속인을 누락시킨 탓으로 그 누락된 상속인이 피고로 되지 않은 채 제1심판결이 선고된 경우에 원고는 항소심에서 그 누락된 상속인을 다시 피고

로 정정추가할 수 없다(대법원 1974. 7. 16. 선고 73다1190 판결).

한편 원고가 사망자인 경우는 다르다. 제1심법원에 소장이 접수되기 전에 원고로 표시된 사람이 사망한 경우 그 원고 명의의 제소는 부적법하고, 사망자의 상속인들에 의한 소송수계신청도 허용될 수 없다(대법원 1979. 7. 24. 자 79마173 결정). 다만 판례는 당사자가 소송대리인에게 소송위임을 한 다음 소제기 전에 사망하였는데 소송대리인이 당사자가 사망한 것을 모르고 그 당사자를 원고로 표시하여 제기한 소는 적법하고, 이 경우 민사소송법 233조 1항이 유추적용되어 사망한 사람의 상속인들은 그 소송절차를 수계하여야 한다고 한다(대법원 2016. 4. 29. 선고 2014다210449 판결). 한편 상속인이 전치절차 중 사망한 피상속인 명의로 조세부과처분취소소송을 제기한 경우에는 실제 그 소를 제기한 사람은 상속인이라고 보아야 할 것이므로 당사자표시정정이 가능하다(대법원 1994. 12. 2. 선고 93누12206 판결).

(3) 종중 관련 소송

종중이 당사자로 되어 있는 소송에서는 종중의 실체가 불명확하고 유동적인 경우가 많아 당사자 확정에 어려움이 발생한다.

종중이 원고인 경우, 소장에 원고로 표시한 종중이 당사자가 되는 것이 원칙이지만, 종중의 명칭만으로는 종중의 실체가 명확히 드러나지 않는 경우가 많으므로 청구원인이나 소장에 첨부된 종중규약을 참고하여 당사자를 확정한다. 즉 공동선조의 후손들 전부를 구성원으로 하고 있다면 고유 의미의 종중이 당사자가 되지만, 그렇지 않다면 유사종중이 당사자가 된다.

한편 당사자의 확정은 원고의 소제기행위의 해석 문제이므로 소장 및 소제기 당시를 기준으로 판단되어야 한다. 따라서 구성원의 범위 등 그 실체에 관한 사실을 당초의 주장과 달리 주장하면서 원고의 실체를 변경하는 것(대법원 1999. 7. 27. 선고 99다9523 판결, 대법원 1999. 8. 24. 선고 99다14228 판결), 원고 종중의 공동선조를 변경하는 것(대법원 1994. 10. 11. 선고 94다 19792 판결)은 모두 당사자변경에 해당하여 허용될 수 없다. 그러나 소송 당

사자인 종중의 법적 성격에 관한 당사자의 법률적 주장이 무엇이든 그 실체에 관하여 당사자가 주장하는 사실관계의 기본적 동일성이 유지되고 있다면 그 법적 주장의 추이를 가지고 당사자변경에 해당한다고 할 것은 아니다. 그 경우 법원은 직권으로 조사한 사실관계에 기초하여 당사자가 주장하는 단체의 실질이 종중인지 혹은 종중 유사단체인지, 공동선조는 누구인지 등을 확정한 다음 그 법률적 성격을 달리 평가할 수 있는 것이고, 이를 기초로 당사자능력 등 소의 적법 여부를 판단하여야 한다(대법원 2016. 7. 7. 선고 2013다 76871 판결).

피고가 종중인 경우에도 소장에 기재된 종중의 명칭, 소장에 첨부된 종중 규약이 당사자를 특정하는 중요한 기준이 되고, 피고로 확정된 종중이 실제로 존재하지 않는 경우 원고는 실질적으로 동일한 단체를 가리키는지 여부에 따라 당사자표시정정의 방법으로 잘못을 시정할 수 있다.

3. 당사자표시의 정정

소제기 당시에 확정된 당사자의 표시에 의문이 있거나 당사자가 정확히 표시되지 않은 경우에 그 표시를 정확히 정정하는 것을 '당사자표시정정'이라 한다. 당사자표시정정은 원칙적으로 당사자의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서만 허용된다는 점에서 후술하는 '당사자의 변경'과 구별되나, 실제에서 단순한 당사자의 표시정정인지 당사자의 변경인지 그 한계를 가리기가 쉽지 않다.

당사자표시정정이 이루어지는 경우로는 공부상의 기재에 비추어 당사자의 이름이 잘못 기재된 경우와 같이 명백하게 잘못 기재된 경우가 있고, 당사자능력이 없는 대상을 당사자로 잘못 표시한 것이 명백한 경우 등이 있다. 개인이 설립 경영하는 학교시설에 불과한 학교를 피고로 표시한 경우 개인 명의로 피고표시를 정정할 수 있다(대법원 1978. 8. 22. 선고 78다1205 판결). 당사자능력이나 당사자적격이 없는 자를 당사자로 잘못 표시한 경우에 당사자

의 표시를 정정·보충시키는 조치를 취하여야 하고 이러한 조치를 취함이 없이 단지 원고에게 막연히 보정명령만을 명한 후 소를 각하하는 것은 위법하다고 판단한 판례(대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결, 대법원 2019. 11. 15. 선고 2019다247712 판결)가 있다.

당사자표시정정신청이 있을 경우에는 문건으로 전산입력하고, 법원으로서 는 당사자를 확정된 연후에 원고가 정정신청한 당사자표시가 확정된 당사자의 올바른 표시이며 동일성이 인정되는지의 여부를 살피고, 그 확정된 당사자로 피고의 표시를 정정하도록 하는 조치를 취하여야 한다(대법원 1996. 10. 11. 선고 96다3852 판결). 따라서 소장에 표시된 당사자가 잘못된 경우에 정당한 당사자능력이 있는 사람으로 당사자표시를 정정하게 하는 조치를 취함이 없이 바로 소를 각하할 수는 없다(대법원 2001. 11. 13. 선고 99두2017 판결, 대법원 2002. 3. 29. 선고 2001다83258 판결).

만약 표시정정을 허용할 경우에는 별도의 명시적인 결정을 할 필요 없이 이후의 소송절차(기일통지, 조서작성, 판결서 작성 등)에서 정정신청된 바에 따라 당사자의 표시를 하면 된다. 그러나 당사자표시정정은 당사자의 신청이 있을 때에 한하여 허용되고, 이는 소장에서의 필수적 기재사항인 당사자표시를 정정하는 것이므로 소변경신청서에 준하여 당사자에게 송달하고 변론(준비)기일에 이를 진술하는 것이 실무이다.

반대로 정정신청을 불허할 경우에는 반드시 즉시 불허의 결정을 하여야 한다(이후의 소송절차에서는 종전대로 표시를 하게 될 것이다). 정정신청이 불허될 경우는 주로 당사자가 변경되는 결과가 생기는 경우일 것인데, 만약 즉시 불허의 결정을 하지 아니한 채 만연히 새로운 당사자를 대상으로 하여 이후의 절차를 진행하였다가 종국판결 단계에서 정정신청을 불허하게 된다면 판결절차가 위법하게 되는 결과가 될 수 있어 부당하기 때문이다.

다만 법원이 원고의 부적법한 당사자표시정정신청(회사의 대표이사이었던 자의 개인 명의로 제기된 소송에서 그 개인을 회사로 당사자표시를 정정하는 것으

로 신청)을 받아들이고 피고도 이에 명시적으로 동의하여 정정된 원고와 피고 사이에 변론이 진행된 다음 본안판결이 선고된 경우에는 당사자표시정정 신청의 적법성을 문제 삼는 것은 소송경제나 신의칙 등에 비추어 허용될 수 없다(대법원 2008. 6. 12. 선고 2008다11276 판결).

한편 당사자가 변경되는 결과가 되어 당사자표시정정이 허용될 수 없는 경우에도, 당사자의 변경에 대한 설명에서 보는 바와 같이 필수적 공동소송인의 추가, 예비적·선택적 공동소송인의 추가, 피고의 경정이 허용되고 있음을 감안하여 적절한 석명 등을 할 수는 있을 것이다.

제3절 당사자능력

1. 총 설

‘당사자능력’이란 일반적으로 소송당사자가 될 수 있는 소송법상의 권리능력, 즉 자기의 이름으로 재판을 청구하고 또는 재판을 받을 수 있는 자격을 말한다. 당사자능력의 존재는 소송요건의 하나이므로 법원은 의심이 있으면 직권으로 이를 조사하여야 하고, 조사 결과 당사자능력이 없으면 소를 각하하여야 한다. 당사자능력이 있는지 여부의 판단 기준 시점은 사실심 변론종결일이다(대법원 1991. 11. 26. 선고 91다30675 판결).

도롱뇽과 같은 자연물 또는 그를 포함한 자연 그 자체는 당사자능력이 인정되지 아니한다(대법원 2006. 6. 2. 자 2004마1148 결정).

당사자능력이 없다고 인정되어 소를 각하할 때의 소송비용은 원고가 당사자능력이 없는 경우에는 사실상 제소행위를 한 사람에게 부담시키고, 피고가 당사자능력이 없는 경우에는 원고에게 부담시켜야 할 것이다.

당사자능력의 흠을 간과한 판결은 원칙적으로 무효인데, 다음과 같이 나누어 볼 수 있다. ① 당사자가 소제기 이전에 이미 사망한 사실을 간과한 판

결은 당연무효이다(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000다33775 판결). ② 어떠한 단체가 실제로 존재하지 않음에도 불구하고 그 단체가 존재하고 그 대표자로 표시된 자가 대표자 자격이 있는 자인 것으로 오인하여 가처분결정이 내려졌다고 하더라도, 그 단체가 실제로 존재하지 않는다면 그 가처분결정은 누구에게도 효력을 발생할 수 없는 무효이고, 당사자능력이 없는 단체를 상대로 보전처분 결정이 내려진 다음 그 단체의 대표자로 표시된 자가 그 단체의 이름으로 보전처분 이의신청을 하거나 항고를 제기한 경우에도 법원은 그 당사자능력에 관하여 별도로 조사 판단하여야 하는 것이지 가처분결정이 외형상 존재한다는 사실만으로 그 기속을 받아 실제로 존재하지 아니하는 단체의 당사자능력을 인정할 것은 아니고, 보전처분에 대한 이의신청 또는 항고는 부적법한 것으로서 각하되어야 한다(대법원 1994. 11. 11. 선고 94다14094 판결, 대법원 2008. 7. 11. 자 2008마520 결정). ③ 다만 실종선고의 효력이 발생하기 전에는 실종기간이 만료된 실종자라 하여도 소송상 당사자능력을 상실하는 것은 아니므로 실종선고 확정 전에는 실종기간이 만료된 실종자를 상대로 하여 제기된 소도 적법하고 실종자를 당사자로 하여 선고된 판결도 유효하며 그 판결이 확정되면 기판력도 발생한다고 할 것이므로 이러한 경우에는 개별적인 재심 또는 추후보완상소의 요건을 갖춘 경우에 이를 취소할 수 있다(대법원 1992. 7. 14. 선고 92다2455 판결).

2. 법인이 아닌 사단 등의 당사자능력

‘법인이 아닌 사단이나 재단’을 당사자로 할 때에는 민사소송법 52조에 의하여 당사자능력 자체가 있는지의 여부를 신중히 검토하여야 한다. 판례는 이 규정에 의한 당사자능력 인정의 요건을 ‘일정한 목적을 가진 다수인의 결합체로서 그 결합체의 의사를 결정하고 업무를 집행할 기관들 및 대표자 또는 관리인에 관한 정함이 있는 법인이 아닌 단체’이어야 한다고 판시하고 있다(대법원 1997. 12. 9. 선고 97다18547 판결).

‘법인이 아닌 사단’이라고 할 수 있기 위해서는 실체에 있어서 법인격 있는 사단과 같은 단체로서의 조직을 갖추어야 하고, 어느 정도의 존속기간을 가지면서 구성원으로부터 독립적이어야 하며, 대표의 선임방법, 총회의 운영 기타 사단으로서의 중요한 점은 정관에 의하여 확정되어 있어야 한다.

‘법인이 아닌 재단’은 일정한 재산을 중심으로 하여 사회생활상 하나의 단위를 이루는 조직을 가지고 개인으로부터 독립한 관리기구(관리인)를 두어야 한다.

법인이 아닌 사단이나 재단이 민사소송법 52조에 의하여 당사자가 될 경우 원고가 그 대표자 또는 관리인의 권한을 증명하는 서면을 소장에 붙여서 법원에 내야 하며(민소 64조, 58조, 민소규 63조 1항), 법원은 이러한 경우 정관·규약, 그 밖에 그 당사자의 당사자능력을 판단하기 위하여 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다(12조).

당사자능력의 판단은 직권조사사항이기는 하지만, 이에 관한 자료는 당사자 자신이 가장 많이 가지고 있는 것이 보통이고, 또 소송의 당사자가 된 이상 원고든 피고든 간에 자신의 당사자능력에 관한 자료를 제출하는 등 그 판단에 협력할 의무가 있음은 당연하다. 민사소송규칙 12조에서 ‘정관·규약’이라고 하는 것은 반드시 민법상의 그것에 한정하는 취지는 아니고, 그 사단 또는 재단에서 정관·규약이라고 칭하는 것이나 이에 상응하는 규칙·약정 등을 의미하는 넓은 개념이다. 또 ‘그 밖에 그 당사자의 당사자능력을 판단하기 위하여 필요한 자료’는 한정되어 있지 않고, 그 사단 또는 재단의 창립총회의사록 등 당사자능력의 판단에 도움을 줄 수 있는 자료를 총칭하는 것이다.

다만 위 규정은 훈시적인 것으로서 해당 자료의 제출을 강제할 수는 없다. 법원의 제출요구에 당사자가 응하지 아니하는 경우에 그 당사자에게 별도의 불이익을 가할 수는 없고, 법원은 직권으로 당사자능력의 유무를 판단하여야 한다.

당사자능력 유무를 판단할 때에는 당사자가 내세우는 단체의 목적, 조직, 구성원 등 단체를 사회적 실체로서 규정짓는 요소를 갖춘 단체가 실재하는지의 여부만을 가려 그와 같은 의미의 단체가 실재한다면 그로써 소송상 당사자능력은 충족되는 것이고, 그렇지 아니하다면 소를 부적법한 것으로서 각하하여야 하는 것이지, 당사자의 주장과는 전혀 다른 단체의 실체를 인정하여 당사자능력을 인정하는 것은 소송상 무의미하고 당사자를 변경하는 결과가 되어 허용될 수 없다(대법원 2002. 5. 10. 선고 2002다4863 판결).

3. 법인이 아닌 사단 등의 당사자능력이 문제 된 사례

먼저, 종교단체에 관하여 보면, 개신교의 개별 교회는 일반적으로 당사자능력을 인정하나(대법원 1991. 11. 26. 선고 91다30675 판결, 대법원 2001. 6. 15. 선고 99두5566 판결), 천주교단에 속한 개별 교회에 대하여는 당사자능력을 부정한다(대법원 1966. 9. 20. 선고 63다30 판결). 사찰의 경우에는 독립된 단체성을 갖추었는가 아니면 개인사찰이거나 불교목적시설에 불과한 것인가에 따라 당사자능력 유무의 판정이 달라지는데, 통상 단체성이 있는 일반사찰(대법원 1988. 3. 22. 선고 85다카1489 판결, 대법원 2000. 5. 12. 선고 99다69983 판결, 대법원 2001. 1. 30. 선고 99다42179 판결)이나 불교신도회(대법원 1991. 10. 22. 선고 91다26072 판결, 대법원 1996. 7. 12. 선고 96다6103 판결) 등은 법인이 아닌 사단으로, 전통사찰은 법인이 아닌 재단으로 각각 권리능력이 인정되는 경우가 많으나, 이에 반해 단체성이 없는 개인사찰이나 불교목적시설에 불과한 경우에는 당사자능력이 부정된다(대법원 1991. 2. 22. 선고 90누5641 판결, 대법원 1994. 6. 28. 선고 93다56152 판결, 대법원 2005. 6. 24. 선고 2003다54971 판결).

그 밖의 단체로서 당사자능력이 인정된 예로서는, 종중·문중 등의 종족단체(대법원 1997. 11. 14. 선고 96다25715 판결), 제중(堤中)·보중(湫中)·수리계(水利契) 등의 농민단체(대법원 1995. 11. 21. 선고 94다15288 판결), 동회(洞會)·자

연부락·아파트입주자대표회의 등 주민단체(대법원 1991. 4. 23. 선고 91다 4478 판결, 대법원 1999. 1. 29. 선고 98다33512 판결), 구 주택건설촉진법에 의하여 설립된 재건축조합과 주택조합(대법원 2001. 5. 29. 선고 2000다10246 판결), 주택재개발정비사업을 위한 추진위원회(대법원 2016. 12. 15. 선고 2013두17473 판결), 설립중의 회사, 채권청산위원회(대법원 1968. 7. 16. 선고 68다736 판결), 청산 중의 법인이 아닌 사단(대법원 2007. 11. 16. 선고 2006다41297 판결), 직종별단체, 동창회, 정당 등이 있다.

또한 하부조직이라 하더라도 독자적인 규약을 가지고 독립한 활동을 하고 있는 등 독자적인 사회적 조직체로 인정되는 한 법인이 아닌 사단으로서 당사자능력이 있다(대한예수교장로회총회신학연구원 이사회; 대법원 1998. 7. 24. 선고 96누14937 판결, 전국출판노동조합지부; 대법원 1979. 12. 11. 선고 76누189 판결, 전국해운노동조합 목포지부; 대법원 1977. 1. 25. 선고 76다2194 판결, 낙농협동조합지소; 대법원 1976. 7. 13. 선고 74다1585 판결, 그러나 대한상이용사회분회의 당사자능력은 부정; 대법원 1961. 2. 27. 선고 4292행상134 판결).

이에 반해 단체로서의 독자성 없이 단지 다른 단체의 부속기관 또는 내부 조직에 지나지 않는 경우에는 당사자능력이 없다. 그러한 이유로 지방자치단체의 하부 행정구역에 불과한 읍·면(대법원 2002. 3. 29. 선고 2001다83258 판결), 단체의 기관에 불과한 노동조합선거관리위원회(대법원 1992. 5. 12. 선고 91다37683 판결), 전국버스운송사업조합연합회 산하의 부속기관에 불과한 같은 연합회 공제조합(대법원 1991. 11. 22. 선고 91다16136 판결), 대한불교조계종의 하부조직 또는 기구에 불과한 대한불교조계종 총무원(대법원 1967. 7. 4. 선고 67다549 판결) 등은 모두 당사자능력이 부정된다.

법인이 아닌 사단은 구성원의 개인성과는 별개로 권리의무의 주체가 될 수 있는 독자적인 단체적 조직을 가지는 데 비하여 조합은 구성원의 개인성이 강하게 드러나는 인적결합체라는 특성이 있다(대법원 1992. 7. 10. 선고 92다2431 판결). 따라서 독자적인 당사자능력이 인정되지 않는다(동백홍농계;

대법원 1974. 9. 24. 선고 74다573 판결, 원호대상자광주목공조합; 대법원 1991. 6. 25. 선고 88다카6358 판결, 부도난 회사의 채권단; 대법원 1999. 4. 23. 선고 99다4504 판결). 당사자능력을 갖는 사단이나 이를 갖지 못하는 조합이나의 구별은 일반적으로 그 단체성의 강약을 기준으로 그 명칭에 구애받음이 없이 실질에 의하여 판단하여야 한다(대법원 1999. 4. 23. 선고 99다4504 판결).

한편 대학교장학회(숙명여자대학교장학회를 법인이 아닌 사단으로 본 예로서 대법원 1961. 11. 23. 선고 4293행상43 판결), 옥영회, 보육원, 유치원(당사자능력을 긍정한 예로는 대법원 1968. 4. 30. 선고 65다1651 판결, 대법원 1969. 3. 4. 선고 68다2387 판결, 부정한 예로는 대법원 1965. 8. 31. 선고 65다693 판결) 등이 법인이 아닌 사단 또는 재단에 해당할 수 있으나, 학교(대법원 1977. 8. 23. 선고 76다1478 판결), 서울특별시립 노원시각장애인복지관(대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673 판결), 노인요양원이나 노인요양센터(대법원 2018. 8. 1. 선고 2018다227865 판결), 학교비(學校費, 대법원 1991. 4. 23. 선고 91다3987 판결)는 시설이나 회계에 불과하므로 당사자능력이 부정된다.

제4절 소의 종류와 당사자적격

1. 총 설

‘당사자적격’이란 특정의 소송사건에서 정당한 당사자로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격을 말한다. 당사자능력과 소송능력이 민법상의 권리능력과 행위능력에 대응하는 개념이라면, 당사자적격은 소송수행권의 귀속자, 즉 민법 등 실체법상의 관리처분권에 대응하는 개념이다. 특히 고유필수적 공동소송에서는 합일확정될 공동소송인 모두가 공동으로만 당사자적격을 가지므로, 여러 사람이 공동으로 원고가 되거나 피고가 되지 않으면 당사자적격의 흠결로 부적법 각하된다.

2. 이행의 소

이행의 소는 이행청구권의 확정과 피고에 대한 이행명령을 목적으로 하는 소송이다. 이행의 소는 실체법상의 청구권이 그 바탕이 되어야 한다. 물권, 채권이나 사원권 등 사법상의 권리에 기초한 청구권뿐만 아니라 공법상의 청구권이라도 민사소송 사항이라면 무방하며, 청구의 내용이 금전 지급, 물건 인도, 의사표시, 작위 또는 부작위 어느 것을 구하는 것이어도 상관없다. 이행청구의 소를 인용하는 판결이 확정되어 집행문이 부여되면 그 판결은 집행력 있는 집행권원으로서 집행력이 생긴다.

이행의 소에서는 자기가 이행청구권자임을 주장하는 사람이 원고적격을 가지고 그로부터 이행의무자로 주장된 사람이 피고적격을 가지는 것으로서, 원고의 주장 자체에 의하여 당사자적격 유무가 판가름되며, 원고·피고가 실제로 이행청구권자이거나 이행의무자임을 요하는 것이 아니다(대법원 1994. 6. 14. 선고 94다14797 판결). 그러한 이행청구권이나 이행의무의 존부는 본 안에서 판단할 사항이다.

다만 예외적으로 등기말소청구의 소가 등기의무자(등기명의인이거나 그 포괄승계인)나 등기상 이해관계 있는 제3자가 아닌 타인을 피고로 삼은 때에는 당사자적격을 그르친 것으로서 각하되어야 한다(대법원 1994. 2. 25. 선고 93다39225 판결). 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구는 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 따라 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로서, 현재의 등기명의인을 상대로 하여야 하고 현재의 등기명의인이 아닌 자는 피고적격이 없다(대법원 2017. 12. 5. 선고 2015다240645 판결). 부기등기에 의하여 이전된 근저당권 또는 가등기 등의 말소등기청구는 양수인만을 상대로 하면 족하고 양도인은 그 말소등기청구의 피고적격이 없다(대법원 1994. 10. 21. 선고 94다17109 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 2000다5640 판결).

채권에 대한 압류 및 추심명령이 있더라도 채무자가 제3채무자를 상대로

피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다(대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결). 추심명령이 제3채무자에게 적법하게 송달되지 아니하여 효력이 발생하지 아니하였다면 추심채권자는 추심의 소를 제기할 권능이 없으므로 추심의 소는 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014다54366 판결).

3. 확인의 소

확인 소는 권리 또는 법률관계의 존부의 확정을 목적으로 하는 소송이다. 확인의 소는 적극적 확인의 소와 소극적 확인의 소로 분류되며, 원칙적으로 권리 또는 법률관계만이 확인의 소의 대상이 되나, 법률관계를 증명하는 증거가 진정으로 작성되었는지 여부의 사실 확인이 예외적으로 허용된다(민소 250조). 확인의 소에 관한 소의 이익에 관하여는 제16장(소의 제기) 제5절 참조. 한편 소송 중에 허용되는 특수한 형태로서 중간확인 소(264조)가 있는데 원고 승소의 확인판결이 나면 원고가 주장하는 법률관계의 존재에 관해 기판력은 생기나 집행력은 발생하지 않는다.

확인 소에서는 그 청구에 관하여 확인의 이익을 가지는 사람이 원고적격을, 그 확인에 대한 반대의 이익을 가지는 사람이 피고적격을 각각 가진다. 회사의 주주총회결의·이사회결의의 부존재확인·무효확인 소에서는 회사만이 피고적격을 가진다(그 결의에서 이사 등 임원으로 선임된 개인은 피고적격이 없다. 대법원 1996. 4. 12. 선고 96다6295 판결). 마찬가지로 종중의 대의원회결의부존재·무효를 이유로 한 종중대표자 지위확인 소나, 노동조합과 같은 독립된 단체의 임원선거에 따른 당선자 결정의 무효 여부에 대한 확인을 구하는 소에서도 그 종중(대법원 1998. 11. 27. 선고 97다4104 판결)이나 조합(대법원 1992. 5. 12. 선고 91다37683 판결)만이 피고적격을 가진다. 다만 단체의 대표자를 선출한 결의의 무효 또는 부존재확인을 구하는 소송에서 피고로 되는 그 단체를 대표할 사람은 여전히 다투어지는 대상이 된

결의에 의하여 선출된 대표자이나(대법원 1983. 3. 22. 선고 82다카1810 전원합의체 판결), 대표자에 대하여 직무집행정지가처분 결정이 내려진 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 대표자는 본안소송에서 그 단체를 대표할 권한이 없다(대법원 2024. 4. 12. 선고 2023다313241 판결).

4. 형성의 소

형성의 소는 법률관계를 변동시키는 판결을 목적으로 하는 소송이다. 형성의 소는 법률에 명문의 규정으로 허용되는 경우에만 인정하는 것이 원칙이며, 그러한 특별규정 없이 제기된 소는 부적법하다(대법원 1993. 9. 14. 선고 92다35462 판결). 예컨대 법인이 아닌 사단의 총회에 절차상의 하자가 있으면 원칙적으로 총회결의무효사유가 된다 할 것이고 따로 총회결의취소의 소를 인정할 법적 근거가 없으므로 임시총회결의의 취소를 구하는 소는 부적법하다(대법원 1993. 10. 12. 선고 92다50799 판결). 또한 조합의 이사장 및 이사가 조합업무에 관하여 위법행위 및 정관위배행위 등을 하였다는 이유로 그 해임을 청구하는 소송도 형성의 소에 해당하는데 이를 제기할 수 있는 법적 근거가 없으므로, 조합의 이사장이나 이사에 대한 해임청구의 소를 본안으로 하는 직무집행정지 가처분은 허용될 수 없다(대법원 2001. 1. 16. 선고 2000다45020 판결).

형성의 소에서는 각 근거법규 자체에서 원고적격자와 피고적격자를 정해 놓고 있는 경우가 많고, 법규 자체에서 명시되지 않은 때에도 판례에 의해서 제한되고 있는 경우가 있다. 예컨대 주주총회결의취소의 소에서 원고적격자가 주주·이사 또는 감사임은 상법 376조에 규정되어 있고, 피고적격자에 관하여는 판례가 회사만으로 제한하고 있다(대법원 1982. 9. 14. 선고 80다2425 전원합의체 판결). 또 사해행위취소의 소에서 원고적격자가 채권자임은 민법 406조에 규정되어 있고, 피고적격자에 관하여는 판례가 채무자가 아니라 수익자 또는 전득자로 제한하고 있다(대법원 1991. 8. 13. 선고 91다13717

판결). 형성판결은 대세적 효력 때문에 법률관계의 안정을 위하여 명문으로 제소기간까지 한정하여 놓은 경우가 많이 있다(상법 184조 1항, 376조 1항).

형성의 소는 다시 '실체법상 형성의 소'와 '소송법상 형성의 소' 및 '형식적 형성의 소' 세 가지 종류로 구분할 수 있다.

먼저 '실체법상 형성의 소'는 실체법상의 권리관계의 변동을 구하는 것으로 각종의 가사소송, 회사관계소송 등이 이에 속한다.

다음으로 '소송법상 형성의 소'는 소송법상 법률관계의 변동을 목적으로 하는 것으로서 재심의 소(민소 451조), 준재심의 소(461조), 제권판결에 대한 불복의 소(490조), 중재판정취소의 소(중재법 36조) 및 정기금판결에 대한 변경의 소[민소 252조, 자세한 설명은 제16장(소의 제기) 제5절 참조]가 이에 속한다. 또한 청구에 관한 이의의 소(민집 44조), 집행문부여에 대한 이의의 소(45조), 제3자의이의 소(48조) 등 민사집행법상의 이의의 소도 종래 존재하였던 소송법상의 효과를 소멸시키는 것으로서 '소송법상 형성의 소'에 속한다.

마지막으로 '형식적 형성의 소'는 소송사건의 형식을 취하지만 실질은 비송사건인 경우로서 경계확정의 소(대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41792 판결, 대법원 1996. 4. 23. 선고 95다54761 판결), 공유물분할의 소(민법 269조, 대법원 1997. 9. 9. 선고 97다18219 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004다10183 판결), 법정지상권이 성립된 경우 그 지료를 결정하는 소(366조 단서, 대법원 2001. 3. 13. 선고 99다17142 판결), 아버지를 정하는 소(845조, 가소 27조) 등이 있다.

제5절 제3자의 소송담당

1. 총 설

소송의 목적이 된 실체법상 권리관계의 주체만이 반드시 당사자가 되는 것이 아니고, 제3자가 타인의 권리의무에 대하여 소송수행권을 갖고 당사자로 소송을 하는 경우가 있다. 이 경우를 ‘제3자의 소송담당’이라 하며, 이는 다시 ‘법정 소송담당’과 ‘임의적 소송담당’으로 나누어 볼 수 있다.

2. 법정 소송담당

가. 총 설

법정 소송담당은 권리관계의 주체는 아니면서 제3자가 법률의 규정에 의하여 관리권을 가지게 되어 그 자격에 의하여 당사자로 되는 경우이다. 여기에는 법이 제3자에게 관리처분권을 부여한 결과 소송수행권을 갖게 되는 경우(아래 ‘갈음형’과 ‘병존형’)와 그러한 관리처분권 없이 일정한 직무에 있는 자에게 소송수행권을 갖게 하는 ‘직무상의 당사자’가 있다. 이러한 법정 소송담당으로 당사자가 된 사람이 그 자격을 잃거나 죽은 때에는 그 소송절차는 중단되며, 같은 자격을 가진 사람이 소송절차를 수계하여야 한다(민소 237조).

나. 갈음형

법정 소송담당 중 실체적 권리관계의 주체 이외의 제3자만이 일정한 자격에 기하여 권리관계의 주체를 갈음하여 단독으로 소송수행권을 가지는 ‘갈음형’의 경우에는 그 자격을 표시하는 것이 원칙이고, 그 판결의 효력이 당연히 본인에게 미친다. 다만 아래 (5), (6)항의 경우에는 실무상 ‘당사자표시’란에 그 자격을 기재하지 않고 있다. 이 경우 당사자표시는 소송법상의 지위를 밝히는 데 불과하므로 실체법상의 권리관계와는 상관이 없으며, 당사자적격을

상실한 권리주체인 사람은 공동소송적 보조참가(민소 78조)를 함으로써 자신의 이익을 보호받을 수 있을 것이다. 실무상 아래와 같은 경우가 이에 해당한다.

(1) 파산관재인(채무자회생 359조)

파산관재인이 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 492조 10호에 의하여 소를 제기하거나 같은 조 11호에 의한 재판상 화해를 함에 있어서 요구되는 감사위원의 동의나 법원의 허가는 민사소송법 51조에 정한 소송행위에 필요한 수권에 해당하여 소제기의 적법요건이 된다고 보아야 한다(대법원 1990. 11. 13. 선고 88다카26987 판결).

(2) 화생절차에서 채무자의 관리인(채무자회생 78조)

법원이 허가사항으로 정한 경우에는 관리인도 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 61조 1항 5호에 의하여 소를 제기하거나 같은 조 6호에 의한 재판상 화해를 함에 있어 법원의 허가를 받아야 하는데, 이때 법원의 허가도 민사소송법 51조에 정한 소송행위에 필요한 수권에 해당하여 소제기의 적법요건이 된다고 보아야 한다.

(3) 유증 목적물 관련 소송에서의 유언집행자(민법 1101조)

유언집행자는 유증의 목적인 재산의 관리 기타 유언의 집행에 필요한 모든 행위를 할 권리의무가 있으므로, 유증 목적물에 관하여 경로된 유언의 집행에 방해가 되는 다른 등기의 말소를 구하는 소송에서는 유언집행자가 법정 소송담당당으로서 원고적격을 가지고, 유언집행자는 유언의 집행에 필요한 범위 내에서는 상속인과 이해상반되는 사항에 관하여도 중립적 입장에서 직무를 수행하여야 하므로, 유언집행자가 있는 경우 그의 유언집행에 필요한 한도에서 상속인의 상속재산에 대한 처분권은 제한되며 그 제한 범위 내에서 상속인은 원고적격이 없다(대법원 2001. 3. 27. 선고 2000다26920 판결).

유증 등을 위하여 유언집행자가 지정되어 있다가 그 유언집행자가 사망·결격 기타 사유로 자격을 상실한 때에는 상속인이 있더라도 유언집행자를 선임하여야 하므로, 유언집행자가 해임된 이후 법원에 의하여 새로운 유언집행

자가 선임되지 아니하였다고 하더라도 유언집행에 필요한 한도에서 상속인의 상속재산에 대한 처분권은 여전히 제한되며 그 제한 범위 내에서 상속인의 원고적격은 인정될 수 없다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2009다20840 판결).

(4) 상속인이 불분명한 경우 법원이 선임한 상속재산관리인(민법 1053조)

재산상속인의 존재가 분명하지 아니한 상속재산에 관한 소송에 있어서 정당한 당사자는 법원에서 선임된 상속재산관리인이고(대법원 1976. 12. 28. 선고 76다797 판결, 대법원 2007. 6. 28. 선고 2005다55879 판결), 이 경우 상속재산관리인은 그의 지위에서 소를 제기하고 이를 수행할 수 있는 것이므로 상속인이 아니라도 상속재산의 소유권확인을 구할 수 있다(대법원 1977. 1. 11. 선고 76다184 판결).

(5) 추심명령을 얻어 추심권을 행사하는 채권자(민집 229조 2항, 238조)

종래 판례는 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있는 경우에는 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고, 실체법상 권리자인 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실하므로(대법원 2000. 4. 11. 선고 99다23888 판결), 채무자가 제기한 소는 부적법하여 각하된다고 하였다.

그러나 대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결은 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 관하여 추심명령이 있더라도 채무자가 제3채무자를 상대로 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 보아야 하고, 이러한 법리는 국가가 국세징수법에 의한 체납처분으로 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류한 경우에도 마찬가지라고 판시하면서 위와 같은 취지의 종래 판례를 위 판결의 견해에 배치되는 범위에서 모두 변경하였다.

(6) 주한미군에 대한 손해배상소송에 있어서의 국가(대한민국과 아메리카합중국간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국군대의 지위에 관한 협정 23조 5항, 동 협정의 시행에 관한 민사특별법 2조)

다. 병존형

법정 소송담당 중 제3의 소송담당자가 원래의 권리관계의 주체와 병존하여 소송수행권을 가지는 이른바 ‘병존형’인 경우에는 제3자의 소송담당관계를 당사자의 표시란에 기재하지 않고 단순히 그 제3자인 당사자의 성명·주소만을 기재하는 것이 실무이다. 이 경우 권리주체인 사람이 판결의 효력을 받게 되는 때가 있는데, 그러한 사람은 자신의 이익보호를 위하여 공동소송적 보조참가(민소 78조) 또는 독립당사자참가 등 소송참가를 할 수 있으며, 소송담당자에 의한 소송고지가 의무화된 경우도 있다(민법 405조 1항, 상법 404조 2항).

(1) 채권자대위권을 행사하는 채권자(민법 404조)

채권자대위소송에서 원고가 채권자가 아님이 판명되면 제3자로서의 소송담당자 자격이 없이 제기된 부적법한 소로서 각하되어야 한다(대법원 1992. 7. 28. 선고 92다8996 판결). 이와는 달리 채권자취소소송에서는 채권자가 수익자나 전득자를 상대로 직접 자신의 권리를 행사하는 것이므로 피보전채권의 존재가 인정되지 않을 경우 소를 각하해서는 안 되고 청구를 기각하는 판결을 해야 한다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다25151 판결).

(2) 질권의 목적인 채권을 행사하는 질권자(민법 353조)

(3) 대표소송에 의하여 이사의 회사에 대한 책임을 추궁하는 소를 제기한 주주(상법 403조)

라. 증권관련 집단소송의 대표당사자

증권관련 집단소송법에 의하여 법원이 선임한 대표당사자는 구성원 전원을 위하여 소송을 수행하고 그 판결의 효력은 제외신고를 하지 아니한 구성원 모두에게 미친다(증집 10조 4항, 37조). 따라서 위 대표당사자는 제외신고기간이 만료되기 전에는 병존형, 제외신고기간이 만료된 후에는 갈음형의 법정 소송담당자로 볼 수 있을 것이다(28조 1항, 2항).

마. 직무상의 당사자

법률이 실체법상의 권리관계와는 아무 상관없이 일정한 직무에 있는 사람에게 특정 소송에 관하여 소송수행권을 갖게 하는 경우를 ‘직무상 당사자’라고 하는데, 아래의 경우 소송담당자격을 표시한다.

- (1) 친족관계소송에 있어서의 검사(민법 849조, 864조, 865조, 가소 24조 3항, 27조 4항, 28조, 31조)
- (2) 피성년후견인의 친생부인의 소에 있어서의 성년후견인(민법 848조 1항)
- (3) 해난구조요청구에 있어서의 선장(상법 894조 2항)

3. 임의적 소송담당

가. 총 설

‘법정 소송담당’이 본인의 의사와 관계없이 제3자가 법률의 규정에 의하여 소송수행권을 갖는 경우라면, ‘임의적 소송담당’은 권리관계의 주체인 자가 그 의사로 제3자에게 자기의 권리에 대하여 소송수행권을 수여한 경우를 말한다.

임의적 소송담당은 변호사 대리의 원칙(민소 87조)을 잠탈하고 신탁법 6조의 소송신탁금지의 취지에 저촉될 염려가 있기 때문에 원칙적으로 허용되지 아니하나, 이를 인정할 합리적 필요가 있을 때에는 법이 명문으로 이를 허용하고 있으며, 그러한 예로 ① 선정당사자(민소 53조), ② 어음의 추심위임배서의 피배서인(어음법 18조), ③ 금융회사등의 부실채권의 회수위임을 받은 한국자산관리공사(한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률 26조 1항)가 있다.

그 밖에 판례는 조합 업무를 집행할 권한을 수여받은 업무집행조합원이 조합재산에 관하여 조합원으로부터 임의적 소송신탁을 받아 자기 이름으로 소송을 수행하는 것을 허용하고(대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다68924 판결), 다수의 채권자가 채권자단의 대표에게 자신들의 채권을 양도하고 그 양도된 채권을 피담보채권으로 한 근저당권을 양수인 명의로 설정받은 경우, 다수

당사자가 권리를 행사하는 불편함을 없애고 채권의 효율적인 회수를 하기 위하여 채권양도를 한 점, 채권양도 및 근저당권설정등기 일자와 근저당권에 기한 임의경매신청 일자 사이의 시간적 간격이 약 2년으로 비교적 길었던 점, 채무자들도 양도인과 양수인 사이의 위와 같은 약정을 용인하고 합의 당사자가 되었던 점 등 제반 사정에 비추어 그 채권양도는 소송행위를 하게 하는 것이 주목적이었다고 볼 수 없다는 이유로 채권자단 대표의 소송수행을 허용하며(대법원 2002. 12. 6. 선고 2000다4210 판결), 집합건물관리단으로부터 집합건물의 관리업무를 위임받은 위탁관리회사가 임의적 소송신탁의 일종으로서 구분소유자 등을 상대로 자기 이름으로 소를 제기하여 관리비를 청구하는 것도 허용하고 있다(대법원 2016. 12. 15. 선고 2014다87885 판결). 그러나 한국음악저작권협회가 저작재산권자로부터 국내에서 공연을 허락할 권리를 부여받았을 뿐 공연권까지 신탁받지 않은 일부 음악저작물에 대하여는 침해금지청구의 소를 제기할 당사자적격이 없다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다87474 판결).

나. 선정당사자

민법상 조합과 같이 그 자체에 당사자능력이 인정되지 않는 경우에는 소송진행의 능률을 기하기 위하여 선정당사자제도를 활용할 수 있다(민소 53조). 선정당사자는 공동의 이해관계 있는 여러 사람 중에서 선정하거나 이를 바꿀 수 있다.

선정당사자의 자격은 서면으로 증명할 것을 요하기 때문에 선정서를 작성하고, 이를 소송기록에 붙여야 한다(민소 58조 1항, 2항). 당사자선정서에는 인지를 붙이지 아니한다. 선정당사자는 당사자 본인이므로 소송대리권의 범위에 관한 민사소송법 90조 2항과 같은 제한을 받지 않는다. 소송계속 후에 선정을 하거나 바꾼 때에는 피선정자(선정당사자) 외의 전 당사자는 당연히 소송에서 탈퇴한다(53조 2항).

당사자표시는 ‘원고(선정당사자)’의 형식으로 선정당사자라는 표기를 괄호 안에 병기하고, 판결서의 말미에는 별지로 선정자들의 성명과 주소를 기재한 ‘선정자 명단’을 작성하여 첨부한다. 이때 ‘선정자 명단’에는 선정당사자도 선정자로서 포함하는 것이 실무이고, 이러한 표기는 위법하다고 볼 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 참조).

한편 선정당사자가 이행판결을 받으면 그 판결에 기하여 선정자를 위하여 또는 선정자에 대하여 강제집행을 할 수 있으므로, 이행판결의 주문에서는 각 선정자가 수령하거나 또는 부담하여야 할 급부의 내용을 개별적으로 명시하는 것이 실무이다. 이 경우 판결의 주문이나 이유에서 선정자들을 표시할 때에는 ‘선정자 ○○○’라고 표시하는 것이 실무이다. 그러나 선정당사자의 청구나 선정당사자에 대한 청구를 기각하거나 각하하는 경우에는 주문에 ‘원고(선정당사자)’ 또는 ‘피고(선정당사자)’라고만 기재하는 것이 실무이다.

4. 판결의 효력

제3자가 소송담당자로서 소송수행한 결과로 받은 판결은 권리관계의 주체인 본인에게 미친다(민소 218조 3항). 제3자의 소송담당 가운데 파산관재인, 회생채무자의 관리인과 같은 ‘갈음형’ 소송담당자, 직무상의 당사자, 그리고 선정당사자 등 임의적 소송담당자의 경우에는 민사소송법 218조 3항이 적용되어 제3자가 받은 판결의 기판력이 권리주체인 사람에게 미치는 것에는 아무런 의문이 없다.

그러나 채권자대위소송을 제기한 채권자, 회사대표소송을 수행하는 주주, 채권에 대한 질권을 행사하는 질권자 등과 같이 제3자가 권리주체인 사람과 병행하여 소송수행권을 갖는 ‘병존형’의 경우에도 제3자가 받은 판결의 효력이 권리주체인 사람에게 미치는지는 논의의 여지가 있다. 만약 전면적으로 기판력이 미친다면, 제3자인 소송담당자가 불성실하게 소송수행을 하여 패소 판결을 받은 경우에도 기판력을 받게 되어 다시 소제기를 못하게 됨으로써,

결국 권리주체인 사람의 소송수행권이 침해·상실되는 결과가 된다. 판례는 그중에서 채권자가 채권자대위소송을 제기하여 받은 판결은 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 알았을 때 채무자에게도 그 효력이 미치는 것으로 보고 있다(대법원 1975. 5. 13. 선고 74다1664 전원합의체 판결). 이때 채무자에게도 기판력이 미친다는 의미는 채권자대위소송의 소송물인 피대위채권의 존부에 관하여 채무자에게도 기판력이 인정된다는 것이고, 채권자대위소송의 소송요건인 피보전채권의 존부에 관하여 당해 소송의 당사자가 아닌 채무자에게 기판력이 인정된다는 것은 아니다. 따라서 채권자가 채권자대위권을 행사하는 방법으로 제3채무자를 상대로 소송을 제기하였다가 채무자를 대위할 피보전채권이 인정되지 않는다는 이유로 소각하 판결을 받아 확정된 경우 그 판결의 기판력이 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권의 이행을 구하는 소송에 미치는 것은 아니다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2011다108095 판결).

제6절 당사자의 변경(소의 주관적 변경)과 피고의 경정

1. 총 설

소송절차의 계속 중에 제3자가 새로 소송에 가입하는 기회에 종전 당사자가 그 소송에서 탈퇴하는 경우를 널리 ‘당사자의 변경’이라 한다. 당사자의 변경, 즉 ‘소의 주관적 변경’은 다시 신당사자가 탈퇴자의 소송상 지위를 승계하는 ‘소송승계’[자세한 내용은 제11장(소송참가와 소송승계) 제5절 참조]와 신당사자가 탈퇴자의 소송상 지위를 승계하지 않는 ‘임의적 당사자변경’으로 나누어 볼 수 있다. 또 ‘임의적 당사자변경’은 종전의 당사자를 갈음하여 제3자를 가입시키는 ‘당사자의 교체’와 종전의 당사자를 그대로 둔 채 누락된 당사자 또는 새로운 당사자를 가입시키는 ‘당사자의 추가’의 두 가지 형태가 있다.

2. 임의적 당사자변경의 허용 여부

당사자의 동일성을 해하지 않는 범위 내에서만 인정되는 ‘당사자표시정정’과는 달리 ‘임의적 당사자변경’은 당사자의 동일성을 해치기 때문에 원칙적으로 허용되지 아니한다.

다만 민사소송법은 소송경제와 당사자의 편의 도모라는 차원에서 3가지 형태의 임의적 당사자변경을 허용하고 있다. ① ‘당사자의 추가’에 해당하는 필수적 공동소송인의 추가(민소 68조), ② 예비적·선택적 공동소송인의 추가(70조), ③ ‘당사자의 교체’에 해당하는 피고의 경정(260조)이 그것이다. 3가지 형태 모두 제1심 변론 종결 시까지에 한하여 가능하며, 그 밖의 임의적 당사자변경은 허용되지 않는다. 그중 앞의 두 가지는 제10장(공동소송) 제3절, 제4절 참조.

3. 피고의 경정

가. 총 설

경정은 피고나 피신청인의 경정만이 가능하며, 소제기자인 원고나 신청인의 경정은 허용되지 아니한다. 따라서 법인이 아닌 사단인 부락의 구성원 중 일부가 제기한 소송에서 당사자인 원고의 표시를 부락으로 정정하거나, 회사의 대표이사가 개인 명의로 소를 제기한 후 회사를 당사자로 추가하고 그 개인 명의의 소를 취하함으로써 당사자의 변경을 가져오는 당사자추가신청은 허용되지 않는다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92다50232 판결, 대법원 1998. 1. 23. 선고 96다41496 판결).

나. 피고경정의 요건

피고의 경정은 ① 원고의 신청에 의하여만 가능하고, ② 원고가 피고를 잘못 지정한 것이 분명한 경우라야 하며, ③ 교체 전후를 통하여 소송물이 동일하여야 하고, ④ 피고가 본안에 관하여 응소한 때, 즉 본안에 관하여 준비

서면을 제출하거나 변론준비기일에서 진술하거나 변론을 한 뒤에는 피고의 동의를 요하며(민소 260조 1항 단서), 피고가 경정신청서를 송달받은 날부터 2주일 내에 이의하지 않으면 동의한 것으로 본다(4항). ⑤ 또한 피고의 경정은 제1심법원이 변론을 종결할 때까지만 가능하다.

이처럼 민사소송법에서는 피고경정이 가능한 범위나 신청권자, 시기 등에서 매우 제한적으로 허용된다. 한편 가사소송법에서는 피고의 경정이 가능한 시기를 사실심의 변론 종결 시까지로 완화하고 있다(가소 15조 1항).

여기서 ‘피고를 잘못 지정한 것이 분명한 경우’란 청구취지나 청구원인의 기재 내용 자체로 보아 원고가 법률적 평가를 그르치는 등의 이유로 피고의 지정이 잘못된 것이 분명하거나 법인격의 유무에 관하여 착오를 일으킨 것이 분명한 경우 등을 말하고, 누가 피고가 되어야 하는지를 증거조사를 거쳐 사실을 인정하고 그 인정 사실에 기초하여 법률 판단을 해야 인정할 수 있는 경우는 이에 해당하지 않는다(대법원 1997. 10. 17. 자 97마1632 결정). 따라서 원고가 공사도급계약상의 수급인으로 기재된 사람을 실제 수급인이라고 주장하면서 그를 피고로 하여 소를 제기하였다가 심리 도중 변론에서 피고 측 답변이나 증거에 따라 이를 번복하여 피고보조참가인이 실제 수급인이라고 하면서 피고경정을 구하는 경우 수급인이 누구인지는 증거조사를 거쳐 사실을 인정하고 그 인정 사실에 기초하여 법률 판단을 하여야 인정할 수 있는 사항이므로, 피고를 잘못 지정한 것이 분명한 경우에 해당한다고 볼 수 없어 피고경정이 허용되지 아니하며, 이러한 경우에는 예비적·선택적 공동소송인으로 추가할 수는 있을 것이다.

실무상 피고경정이 허용되는 예로는, 주식회사를 피고로 하여야 할 것이 명백함에도 그 대표이사 개인을 피고로 한 경우, 지역농업협동조합을 상대로 해야 할 것이 명백함에도 농업협동조합중앙회를 상대로 한 경우를 들 수 있다.

다. 피고경정신청의 방식

피고의 경정은 신소의 제기와 구소의 취하의 실질을 가지므로, 신청권자인 원고가 서면으로 신청하여야 한다(민소 260조 2항). 신청서에는 새로 피고가 될 사람의 이름, 주소와 경정신청의 이유를 적어야 한다(민소규 66조). 새로 피고가 될 사람의 이름, 주소를 적도록 한 것은 경정신청을 허가하는 결정을 한 때에는 새로운 피고에게 그 허가결정의正本과 소장을 송달하여야 하기 때문이다(민소 261조 2항). 청구취지와 청구원인은 그것이 소장에 이미 기재되어 있는 한 새로운 피고에게 소장부분을 다시 송달하므로, 이를 피고경정신청서에 적을 필요가 없다. 그 밖에도 신청서에는 사건의 표시, 신청인과 대리인의 이름, 주소와 연락처, 덧붙인 서류의 표시, 작성한 날짜, 법원의 표시 등을 적고 신청인 또는 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 한다(민소규 2조). 신청서에는 인지를 붙이지 않고 문건으로 전산입력하며 기록에 가철한다(인지액·편철방법예규).

한편 민사소송법의 규정에도 불구하고 소액사건에서는 구술로도 피고경정신청을 할 수 있다고 해석되는데(소액 4조 참조), 그 경우에는 위 기재사항을 말로 진술하면 될 것이다.

라. 피고경정신청에 대한 허부의 재판과 불복

피고경정신청서는 종전의 피고에게 소장부분을 송달하지 아니한 경우를 제외하고는 종전 피고에게 이를 송달하여야 한다(민소 260조 3항). 원고의 피고경정신청에 대하여 법원은 결정으로 허부의 재판을 하여야 하며, 그 허부의 결정은 종전의 피고에게 소장부분을 송달하지 아니한 경우를 제외하고는 종전 피고에게 송달할 것을 요한다(261조 1항). 한편 새로운 피고에 대해서는 경정신청을 허가하는 결정을 한 때에 한하여 결정의正本과 함께 소장부분을 송달하여야 한다(2항).

결정을 허가하는 결정에 대하여는 동의권을 가진 종전 피고가 경정에 부

동의하였음을 사유로 하는 경우에 한하여 즉시항고할 수 있을 뿐이고(민소 261조 3항) 그 밖의 사유로는 불복할 수 없으며, 더욱이 피고경정신청을 한 원고가 그 허가결정의 부당함을 내세워 불복하는 것은 허용될 수 없다(대법원 1992. 10. 9. 선고 92다25533 판결).

피고경정신청을 기각하는 결정에 대하여 불복이 있는 원고는 민사소송법 439조의 규정에 의한 통상항고를 제기할 수 있으므로 그 결정에 대하여 특별항고를 제기할 수는 없다(대법원 1997. 3. 3. 자 97오1 결정).

마. 피고경정 허가결정의 효력

경정허가결정이 있는 때에는 종전의 피고에 대한 소는 취하된 것으로 본다(민소 261조 4항). 따라서 종전 피고에 대하여는 소송계속의 효과가 소멸되었기 때문에 더 이상 그에 관한 심리를 하여서는 안 된다.

피고의 경정은 구소의 취하 및 신소의 제기이므로 종전 피고의 소송진행의 결과는 새로운 피고가 원용하지 않는 한 새로운 피고에게 효력이 없고, 법원은 새로운 피고에 대하여 새로 변론절차를 열어야 하는 것이 원칙이다. 따라서 재판장은 피고경정을 허가한 뒤 첫째 변론기일에 종전 피고의 소송진행 결과를 원용할 것인지 여부를 확인하여 그 취지가 조서에 기재되도록 하여야 할 것이다.

또한 피고의 경정도 새로운 피고에 대하여는 소의 제기에 해당하므로, 그로 인한 시효중단과 기간준수의 효과는 경정신청서의 제출 시에 발생한다(민소 265조).